

1500968-85.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... que o réu disse que assumiu a boca do tráfico desde as 15 horas da tarde; que o dinheiro era proveniente do tráfico; que o réu foi preso e tudo foi encaminhado à autoridade policial; que o depoente não conhecia o acusado; que o réu encontra-se solto, recentemente foi abordado e nada de ilícito portava; que o bairro primavera não foi muito planejado, sendo que o escadão fica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

1500968-85.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500968-85.2021.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

LUÍS FERNANDO DA SILVA, qualificado às fls. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, pois alega-se que, no dia 03 de setembro de 2021, às 23h30min, na Travessa Carlos Romani, 100, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, trazia consigo, para venda, 2 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 0,52g, 2 porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 1,03g, 4 porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 55,01g, 1 porção de crack composta por cerca de 25 pedras, com peso líquido de 4,71g, e 25 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 8,24g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Alega-se que, segundo apurado, "na data dos fatos Policiais Militares estavam exercendo patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado acompanhado de mais duas pessoas em uma escadaria, local conhecido como ponto de tráfico no Bairro Jardim Primavera. Quando visualizaram a viatura, eles saíram correndo, pulando o muro de uma residência abandonada. O denunciado também correu, jogou uma pochete preta e tentou pular o muro, mas foi contido. Em revista, os Policiais localizaram com o denunciado, no bolso traseiro direito da bermuda, R\$ 504,00 em cédulas diversas. No elástico do lado direito da

cueca do mesmo, localizaram dois eppendorfs contendo cocaína e, do lado esquerdo, encontraram duas porções de maconha. Em seguida, entraram na residência abandonada e localizaram um saco plástico contendo cerca de 1.000 eppendorfs vazios, além de uma balança de precisão pequena e diversos sacos plásticos pequenos comumente usados para embalar entorpecentes. Aberta a pochete dispensada pelo denunciado, localizaram mais entorpecentes, consistentes em 4 porções de maconha, 25 eppendorfs de cocaína, além de uma porção de crack composta por cerca de 25 pedras esfarelando. Indagado pelos Policiais Militares, Luís Fernando confessou o tráfico de drogas, assumindo a propriedade dos objetos e entorpecentes, dizendo que estava vendendo drogas desde a tarde e que o dinheiro era fruto da venda. Auto de exibição e apreensão a fls. 11/13 e laudo de constatação a fls. 16/28. Fotografias das drogas, objetos e dinheiro a fls. 45/63.”.

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fl. 01), os termos de declarações na fase policial (fls. 03, 05), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 06), o boletim de ocorrência nº 498/2021 (fls. 08/10), o auto de exibição/apreensão (fls. 11/13), o laudo pericial provisório nº 293.149/2021 (fls. 16/28), bem como as fotografias das drogas, objetos e dinheiro (fls. 45/63). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 69/71, 72, 75). O réu passou por audiência de custódia em 04 de setembro de 2021, oportunidade em que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 87/89). Pela Defensoria Pública foi impetrado em favor do réu Habeas Corpus, em 08 de setembro de 2021, o qual foi deferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 107/120). O alvará de soltura foi cumprido em 08 de setembro de 2021 (fls. 126/127). Vieram aos autos o relatório final do inquérito policial (fls. 139/140). A denúncia foi oferecida (fls. 148), o acusado foi notificado (fl. 164), a defensora do réu apresentou a defesa prévia (fls. 165/170) e posteriormente foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 176/177, 178/198). A denúncia foi recebida (fls. 204/205). O laudo definitivo de entorpecentes nº 306.344/2021 encontra-se às fls. 232/236 e o laudo definitivo de entorpecentes nº 293.150/2021 foram juntados aos autos (fls. 251/259). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 09 de agosto de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas comuns PM Alison Alves, PM Luiz Guilherme Cano, das testemunhas de defesa, quais sejam, Caio Leonardo da Silva Coutinho e Iraci Viana da Silva e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 289).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia, e o perdimento do dinheiro apreendido (art. 63, I, da Lei de Drogas) (fls. 292/302).

A ilustre defensora do réu, em alegações finais, pugnou, em resumo, pela absolvição do acusado pela ausência de provas de que este tenha concorrido com a prática do crime, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal, ou, em caso de entendimento contrário, pugnou pela absolvição do denunciado por não existir provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a prática do delito previsto no artigo 28 da lei 11343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o acusado é usuário de drogas; que, em caso de condenação, deve ser reconhecida a existência de das atenuantes, sendo o réu primário e de bons antecedentes. Por fim, requereu a conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos e ainda que seja a pena fixada no mínimo legal, devendo o acusado apelar em liberdade nos termos do artigo 283 do CPP (fls. 306/310).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pois “in casu” restou

comprovada a materialidade e autoria do ilícito penal descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), nos termos de declarações na fase policial (fls. 03, 05), no termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 06), no boletim de ocorrência nº 498/2021 (fls. 08/10), no auto de exibição/apreensão (fls. 11/13), no laudo pericial provisório nº 293.149/2021 (fls. 16/28), nas fotografias das drogas, objetos e dinheiro (fls. 45/63), no relatório final do inquérito policial (fls. 139/140), no laudo definitivo de entorpecentes nº 306.344/2021 (fls. 232/236) e no laudo definitivo de entorpecentes nº 293.150/2021, bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Segundo o auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), foram apreendidos 01 balança de precisão digital, 01 saco plástico contendo eppendorfs, dinheiro em espécie, totalizando R\$ 504,00 em cédulas diversas, 01 sacola plástica contendo sacos plásticos transparentes, do tipo sacolé, 4,71 gramas de "crack", 27,59 gramas de cocaína, 55,01 gramas de maconha, 02 papелotes de maconha, 02 papелotes de cocaína e 25 microtubos de cocaína.

No laudo pericial definitivo de entorpecentes de nº 306.344/2021 (fls. 231/236), restou consignado: 01 balança digital, contendo fragmentos de pó amarelado sobre a sua superfície, 01 sacola plástica de cor branca, contendo diversos sacos plásticos do tipo "sacolé", sem uso aparente, na qual no interior da sacola foram encontrados fragmentos vegetais e 01 saco plástico contendo microtubos plástico do tipo "eppendorf" de cores verde, amarela e transparente, sendo que nos tubos amarelos e transparente apresentavam-se com sujidades e aparentavam uso, os seguintes resultados: "[...] "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores e DETECTADA presença da substância THC (Tetrahydrocannabinol), constante na Lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

No laudo pericial definitivo de entorpecentes de nº 293.150/2021 (fls. 251/259), restou consignado dá análise dos itens analisados, quais sejam: [...] Item A - saco plástico contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância petrificada de cor bege (na apresentação conhecida popularmente por CRACK). Tal amostra refere-se a um total de 4,71g (quatro gramas e setenta e um centigramas composta originalmente por 1 (uma) porção e teve por resultado: "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Item B - saco plástico contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância em pó branca. Tal amostra refere-se a um total de 27,59g (vinte e sete gramas e cinquenta e nove centigramas), composta originalmente por 1 (uma) porção e teve por resultado: "... DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Item C - Saco plástico transparente, contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de fragmentos vegetais constituído por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Tal amostra refere-se a um total de 55,01g (cinquenta e cinco gramas e um centigrama), composta originalmente por 4 (quatro) porções e teve por resultado: "...DETECTADA presença da substância THC (Tetrahydrocannabinol), constante na Lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Item D - Saco plástico contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de

1,03g (um grama e três centigramas) de fragmentos vegetais constituídos por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Tal amostra refere-se a um total de 1,03g (um grama e três centigramas), composta originalmente por 2 (duas) porções e teve por resultado: "...DETECTADA presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na Lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Item E - saco plástico contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 0,52g (cinquenta e dois centigramas) de substância em pó branca com grânulos amarelados. Tal amostra refere-se a um total de 0,52g (cinquenta e dois centigramas), composta originalmente por 2 (duas) porções e teve por resultado: "... DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Item F - Saco plástico contendo 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância em pó branca. Tal amostra refere-se a um total de 8,24g (oito gramas e vinte e quatro centigramas), composta originalmente por 25 (vinte e cinco) porções e teve por resultado: "... DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Desta forma, não resta dúvida de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sendo que o denunciado não tinha qualquer autorização e ainda se encontravam em desacordo com determinação legal e regulamentar, restando a materialidade devidamente configurada.

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do réu.

O denunciado Luis Fernando da Silva, ao ser interrogado em Juízo, declarou "que não é verdadeira a denúncia; que no dia dos fatos, tinha acabado de descer ao local para comprar baseado e pino de cocaína; que assim que comprou os moleques correram e o interrogado correu também; que quando foi virar a esquina viu mais policiais; que foi pego pelos policiais; que a pochete que tinha drogas não era do interrogado e não chegou a pular muro algum; que a droga do interrogado era só aquelas que estavam na cueca; que todo esse dinheiro era do interrogado porque tinha acabado de receber do "trampo" e da venda de um celular velho; que vendeu o celular para um rapaz que arruma celular; que esse cara é o Cristiano; que o dinheiro também era do serviço de pintura; que estava trabalhando com Paulinho; que não lembra o endereço da obra, mas se recorda que era na rua da Lutepel; que o interrogado usa drogas; que tem controle acerca do uso da droga, trabalha normalmente quando tem serviço; que tem 19 anos, solteiro, não tem filhos, mora com o pai e as irmãs; que nunca foi preso e nem processado; que não tem registro em carteira; que estava sem documento, porque teve problemas para tirar o CPF; que não conhece os policiais e nada tem contra eles; que só levou uns tapas na cara porque os policiais queriam que o interrogado caguetasse os moleques traficantes, mas só isso".

Tal negativa, no entanto, não encontra amparo no quadro probatório presente nos autos, restando, assim, isolada, razão pela qual é rejeitada.

A testemunha Alison Alves, Policial Militar, relatou, em Juízo, "que o depoente é policial militar há 23 anos; que no dia dos fatos era por volta das 23 horas e a escadaria do Jd. Primavera já é conhecido como ponto de venda de drogas, local de fácil fuga; que viram o réu e mais 2 elementos; que ao verem a viatura todos correram; que o réu dispensou uma pochete preta, mas foi detido; que no bolso traseiro direito foram encontrados 504 reais em notas diversas, notas baixas; que no elástico da cueca, de lado, achou 2 eppendorfs do lado direito e do esquerdo, 2 porções de maconha; que na residência próxima foi localizado um saco plástico

contendo quase mil eppendorfs vazios, além de pequena balança de precisão; que trata-se de uma casa abandonada; que também encontraram saquinhos plásticos transparentes; que na pochete havia mais 4 porções de maconha, 25 eppendorfs contendo cocaína, além de 25 pedras crack pequena; que perguntado, o réu assumiu a propriedade dos objetos e da droga na pochete; que o réu disse que assumiu a boca do tráfico desde as 15 horas da tarde; que o dinheiro era proveniente do tráfico; que o réu foi preso e tudo foi encaminhado à autoridade policial; que o depoente não conhecia o acusado; que o réu encontra-se solto, recentemente foi abordado e nada de ilícito portava; que o bairro primavera não foi muito planejado, sendo que o escadão fica no início do bairro; que o escadão dá para a avenida do bairro e dá acesso a outra rua na forma de "U" dando acesso a local em que tem casas; que saindo correndo da escadaria há, à direita, uma casa abandonada a cerca de 15 metros; que é de conhecimento da polícia de que essa casa abandonada é usada pelos traficantes; que em diligência anterior aos fatos já estiveram nessa casa e viram embalagens e resquícios de droga indicando que o local era usado para o rateio e preparo do entorpecente; que essas embalagens encontradas na casa eram idênticas àquelas que estavam seja na bolsa dispensada pelo réu, seja na cueca do acusado; que seja as embalagens, sejam os pinos; que os traficantes portam poucos pinos para fazer a venda rápida; que esse local já é conhecido como ponto de venda de drogas, que ocorre diuturnamente, inclusive é caminho usado por crianças no caminho da escola, havendo grande transito de populares nesse escadão; que quando da fuga viu com certeza quem jogou a pochete, sendo o réu, sendo que o acusado assumiu que a pochete era dele e ele mesmo falou que estava traficando no local desde a tarde; que não viu os outros elementos jogando qualquer coisa; que os outros 2 elementos conseguiram fugir, porque pularam o muro mais rápido; que as embalagens e a balança foram encontradas na residência".

A testemunha Luiz Guilherme Cano, Policial Militar, relatou, em Juízo, "que o depoente é policial militar há 9 anos.; que estava na força tática realizando patrulhamento em torno das 23 horas; que se aproximando da viela, já conhecida como ponto de venda de drogas, havia 3 elementos; que ao verem a viatura, todos correram; que foram em direção a uma casa abandonada; que nessa casa, dois conseguiram se evadir; que o réu foi segurado pelo depoente e pelo cabo Alisson, evitando a fuga; que o depoente viu o réu dispensando uma pochete preta, continuando correndo; que após conter o réu voltaram a pegar a pochete; que na busca pessoal do réu, no bolsos traseiro, foi localizado 504 reais em notas diversas; que nas buscas, no elástico da cueca, lado direito, havia mais 2 pinos de cocaína; que do lado esquerdo, havia um saquinho plástico de maconha pronta para venda.; que na casa abandonada havia um saco plástico grande contendo cerca de 1000 pinos eppendorfs vazios, bem como uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga, semelhante àquele encontrado na cueca; que na pochete dispensada pelo réu continha 4 porções de maconha, iguais à da cueca, 25 pinos de cocaína e 25 pedras de crack, sendo que parte das pedras estavam esfarelado; que havia vários tipos de drogas; que conversando com o réu, esse confessou que a droga era dele, que estava comercializando no local desde o período da tarde e que o dinheiro era proveniente do tráfico; que sempre via o réu no local, às vezes era abordado em frente ao bar, mas nunca tinha nada; que nunca viu o réu trabalhando, nunca exercendo atividade lícita, sendo que o depoente sempre via o réu na biqueira, na parte da parte da tarde e à noite, na madrugada, fica na rua tirando onda, como copão na mão; que já tinham denúncias de que essa casa abandonada era usada por traficantes, que às vezes elementos do tráfico ficam morando lá, como o tal de Paquito; que agora o lugar está queimado pelas prisões realizadas, destelharam a casa, não está mais habitada; que antes a casa tinha água e energia para carregar celular; que havia informação de que essa casa era usada para embalar drogas".

A testemunha de defesa Caio Leonardo da Silva Coutinho, relatou, em Juízo, "que o depoente conhece o réu desde pequeno, pois moraram na mesma rua no Primavera; que não presenciou a atuação da polícia no dia em que o réu foi detido; que não sabe se o réu trabalha; que o réu usa drogas, ao que sabe maconha; que nunca ouviu

comentários de que o réu vendesse drogas; que o depoente não é amigo de Luis Fernando; que conhece o escadão do Jardim Primavera, perto da casa abandonada; que nada sabe acerca da casa abandonada; que Luis mora com o pai e as irmãs; que o réu ajudava o pai com trabalho de pedreiro; que o réu, com 15 anos, já fumava maconha; que a tia falava do uso de drogas realizado pelo réu; que a mãe do réu usava crack e o réu foi criado por uma tia".

A testemunha de defesa Iraci Viana da Silva, relatou, em Juízo, "que a depoente conhece o réu desde pequeno, pois foi a cunha da depoente quem criou o réu; que a depoente não presenciou a atuação da polícia e nem a prisão do réu; que o réu usava maconha; que a depoente não ficou sabendo da prisão do réu; que a depoente não sabe informar se o réu trabalha; que nunca ouviu comentários de que o réu vendesse drogas; que o réu mora com o pai dele, Sr. Alex; que conhece o escadão do Primavera, mas não sabe informar se tem casa abandonada perto; que a depoente conheceu a mãe de Luis e pode informar que ela usava drogas, mas a depoente não sabe informar qual tipo".

Nesse diapasão, a prova oral produzida consubstancia robusto elemento cognitivo no sentido de que o denunciado violou a norma penal incriminadora prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, na medida em que efetivamente trazia consigo, para fins de tráfico, os alucinógenos em questão, bem como tinha dinheiro trocado.

Restou comprovado que, quando dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, na escadaria do Jardim Primavera - local já conhecido como ponto de venda de drogas - avistaram o acusado, na companhia de mais dois indivíduos, os quais empreenderam fuga ao avistar a viatura da Polícia Militar. Foi demonstrado que, durante a fuga, o denunciado dispensou uma bolsa e posteriormente foi detido. Em revista pessoal, com o denunciado foram encontrados R\$ 504,00 em notas trocadas, 02 eppendorfs e 02 porções de maconha no elástico da cueca. Já na pochete que dispensou durante a fuga, continha mais 04 porções de maconha, 25 eppendorfs de cocaína e 25 pedras de "crack".

Restou comprovado também, que na casa abandonada para a qual o réu tentou empreender fuga, foram encontrados uma quantidade significativa de apetrechos para o tráfico, quais sejam, balança de precisão e embalagens.

Consigna-se, ainda, que aos Policiais Militares o réu assumiu a propriedade da droga, bem como dos objetos apreendidos. Relatou, ainda, que estava traficando no local desde o período da tarde e que o dinheiro era proveniente do tráfico.

O réu, em Juízo, relatou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho e da venda de um aparelho celular. Contudo, não restaram comprovadas nos autos seja a atividade lícita do réu, seja a venda do celular, fatos que seriam facilmente comprovados através da oitiva de testemunhas.

Na verdade, a prova dos autos é de que denunciado, às 23 horas da noite, foi visto dispensando a pochete durante a fuga, ressaltando-se que os dois Policiais Militares atestaram, manifestando certeza, que a pochete não foi dispensada pelos outros indivíduos. Assim, o denunciado foi flagrado na posse de droga e de volumosa quantidade de dinheiro trocado. Nota-se que, nas fotografias acostadas nos autos, tem-se que a grande maioria do dinheiro era composta de notas de R\$ 20,00, R\$ 10,00, R\$ 5,00 e R\$ 2,00, ou seja, cédulas miúdas, típicas do tráfico de entorpecentes (fls. 61).

Obtempera-se que os depoimentos pelos policiais que participaram das diligências, seja em Juízo, seja na fase Policial, são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas.

Assim, tendo os policiais atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente

aquilo que presenciaram, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Sinésio de Aquino - RJTJRJ 7/287)

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Apelação Criminal n. 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)".

Mesmo desconsiderando a conexão do réu com a casa abandonada (pois é provável que vários traficantes usassem essa residência), fato é que o volume e forma de acondicionamento da droga apreendida em poder do acusado e na pochete por ele dispensada são compatíveis com o rotineiro comércio de drogas, pois, como é cediço, os traficantes de entorpecentes não mais carregam elevadíssima quantidade consigno, justamente para, no caso de abordagem policial, suscitarem a tese defensiva de porte para uso próprio.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Tráfico ilícito de entorpecente. Réu guardava, no interior de sua residência, a quantidade de 32,75 gramas de crack e 4,12 gramas de cocaína. Pedido de desclassificação para o tipo penal constante do artigo 28, da Lei de Drogas, não contemplado, diante das evidências fáticas e dos depoimentos dos policiais militares. Autoria e materialidade comprovadas. A configuração do crime de tráfico ou de posse para consumo próprio não se submete apenas à análise da quantidade de droga apreendida, devendo outras circunstâncias ser consideradas, tais como o local do flagrante, a conduta e os antecedentes do agente, a existência de notícia anônima. Mormente por considerar a prática comum entre os traficantes de portar poucas porções visando a evitar eventual condenação pelo narcotráfico. Condenação mantida. Reforma das penas. Redutor aplicado à razão máxima. Alteração para regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (TJ-SP - APL: 00042805020118260318 SP 0004280-50.2011.8.26.0318, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/08/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2015) (destaque nosso).

Ressalta-se que a harmonia e homogeneidade dos detalhes, circunstâncias e indícios do caso conforme supra exposto, todos convergentes para a demonstração do espúrio comércio, gera a inabalável conclusão de que o denunciado efetivamente trazia consigo, para venda, o entorpecente destinado ao tráfico.

Logo, ao contrário do alegado pela nobre e combativa Defesa, o quadro probatório é mais que suficiente para lastrear o decreto condenatório, sobretudo considerando que a Defesa não produziu qualquer prova significativa em sentido contrário, restando também afastada tentativa do nobre defensor em desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescentar ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Frisa-se, por fim, que não é possível admitir, com certeza, a conexão do réu com a casa abandonada (pois, como dito, é provável que vários traficantes usassem essa residência). Ademais, a acusação não logrou demonstrar, com a segurança necessária, de que o réu efetivamente integra organização criminosa ou se dedique rotineiramente ao tráfico, como meio de vida.

Logo, diante das circunstâncias do fato, bem como em face da ausência de condenação anterior (cf. certidão de fls. 72), reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa". (STJ - HC - 489.043 - SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJU: 12/03/2019).

Isto posto, passo à fixação da pena.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base no mínimo legal cominado, qual seja, CINCO ANOS DE RECLUSÃO. Não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes e a atenuante da menoridade relativa do réu não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há causas de aumento de pena. Em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tal reprimenda é reduzida em dois terços, perfazendo o total final de UM ANO E OITO MESES.

Tal redução em dois terços justifica-se, pois, o acusado é primário e não há notícias nos autos de sua filiação à organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

O regime inicial de cumprimento da pena seria o fechado, conforme previsão do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos.

No tocante à pena de multa, considerando a situação econômica do agente, fixo-a no mínimo legal cominado, qual seja, quinhentos dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Ausentes causas de aumento de pena. Em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tal reprimenda é reduzida em dois terços, perfazendo o total final de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Ressalta-se, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado. Os Ministros, por maioria de votos, revogaram o dispositivo que impunha o regime fechado, determinando que pessoas condenadas por crime de tráfico tenham direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto (STF - HC 111840 - Rel. Min. Dias Toffoli).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por decisão definitiva, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do dispositivo que vedava essa substituição, induzindo o Senado Federal a suspender sua execução, mercê da Resolução n.º 5/2012, que estabeleceu: "Art. 1.º É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva

do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS. (...)).

Em atenção às recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Superposição de nosso país, altero – à contragosto – o entendimento que outrora vinha adotando.

Assim, passo a decidir da seguinte forma:

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as razões expostas durante a aplicação da pena e a primariedade, e considerando, também, que não se denotou tratar de estruturado tráfico de drogas, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Justifico, por oportuno, que adoto referido regime ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, seguindo entendimento da Corte Suprema cancelou a Súmula 512 e adotou, em sede de Recurso Repetitivo constante do Tema 600 (REsp 1.329.088/RS), a figura do tráfico privilegiado, afastando a hediondez do crime. Ainda, aplico a determinação do Superior Tribunal de Justiça que decidiu no HC Coletivo n. 596.603, de forma vinculante, a aplicação do referido regime aos beneficiados com o tráfico privilegiado. Nesse ponto, merece transcrição a determinação contida no julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, “in verbis”:

"Dispositivo. À vista de todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para: 1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. 3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial fechado de cumprimento da pena."

Por fim, considerando especificamente as peculiaridades desse caso – sobretudo a quantidade de droga apreendida, a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente, as circunstâncias do crime e respectiva periculosidade – reputo possível, em caráter excepcional, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; e outra prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo federal vigente quando do pagamento, tudo com fundamento no artigo 44, § 2º, e artigo 46, do Código Penal. A substituição é permitida, desde que haja requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, assim CONDENO o réu LUÍS FERNANDO DA SILVA, RG: 58125744, filho de Alex dos Santos e Maria de Lourdes da Silva, por infração ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO em regime inicial aberto e CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA,

com valor unitário no mínimo legal. Consigna-se que a pena privativa de liberdade que é substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; e outra prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo federal vigente quando do pagamento.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei n.º 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Considerando o disposto no art. 91, II, do Código Penal em combinação com o art. 63, da Lei n.º 11.343/06, decreto, como corolário da condenação por tráfico, o perdimento dos bens e valores apreendidos nesses autos em favor da União. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 6) Caso no presente feito tenha ocorrido a prestação de fiança, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor correspondente à multa aplicada para o FUNPESP. O saldo remanescente deverá ser utilizado para pagamentos das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal; 7) Em havendo objeto(s) apreendidos, face a ausência de interesse na respectiva conservação, autorizo sua destruição. Comunique-se à 1ª Vara local, responsável pela Seção de Armas e Objetos; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o

evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA